

1502322-25.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... já que a condenação anterior também é por tráfico.

Aumento a pena de 1/6, posto que a traficância ocorria nas imediações de instituição hospitalar (Unidade Básica de Saúde do Jardim Inamar), conforme depoimento dos policiais e "croqui" de fls. 78 (a 86 metros da referida unidade de saúde).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1502322-25.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502322-25.2021.8.26.0537 Controle nº 1681/2021

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", c.c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 21:40 horas, na Rua José Vicente, altura do n.º 79, próximo à UBS - Unidade Básica de Saúde - Jardim Inamar, e na Passagem Rangel, altura do n.º 112, ambos no bairro de Jardim Inamar, nesta cidade de Diadema, adquiriu, recebeu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que a infração foi cometida nas imediações do mencionado estabelecimento hospitalar. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 38/41).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 80/81), sendo recebida a denúncia em 09.03.22 (fls. 86/87). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. A ré foi interrogada no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme

entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, por ser reincidente e pela agravante do art. 40, inc. III, afastando-se a redução do art. 33, §4.º e fixação de regime fechado.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação a fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A acusada negou a prática do crime na fase policial (fls. 10), dizendo que estava apenas com R\$ 60,00 para comprar drogas, pois é usuária de "crack", maconha e cocaína. Falou que não estava com a sacola contendo entorpecentes. Em juízo, narrou que dois meninos correram, jogaram a sacola e ela foi abordada e incriminada. Disse que não estava com a sacola, nem com drogas. Tinha apenas R\$65,00 que era para comprar drogas, porque é usuária de "crack". Afirmou que respondeu por outros tráfico, porque mora na favela e onde tem "ponto de venda". Cuida do seu neto, enquanto sua filha trabalha. Foi xingada pelos policiais e foi revistada por estes. Os guardas municipais, na fase extrajudicial (fls. 07/09), relataram que estavam em patrulhamento quando se depararam com a acusada. Falaram que a acusada aparentava estar nervosa, trazia consigo uma bolsa preta nas costas e uma sacola nas mãos, e resolveram abordá-la. Disseram que a acusada empreendeu fuga, mas conseguiram abordá-la na Rua Passagem Rangel, altura do numeral 112. Narraram que localizaram somente pertences pessoais da acusada na bolsa preta que ela trazia consigo, porém, dentro do saco plástico que ela segurava encontraram 35 invólucros de maconha, 35 invólucros de cocaína e 67 papéletes de "crack", todos embalados e individualizados. Informaram que apreenderam a quantia de R\$ 419,50 com acusada, sendo que R\$ 60,00 estava nas mãos dela e o restante dentro da sacola.

Francisco (GCM), em juízo, afirmou que nas proximidades da UBS do Jd Inamar, viram a ré com uma mochila nas costas e uma sacola nas mãos, a qual demonstrou nervosismo. Na sacola havia drogas (porções de maconha e cocaína) e dinheiro (acima de R\$400,00). Narrou que nas mãos da acusada havia dinheiro (R\$60,00). Não conhecia a ré anteriormente. A ré falou que era usuária, mas a quantidade de drogas apreendidas era bastante (acima de 80 porções). Nas imediações havia pessoas, mas na entrada da viela só estava a acusada, a qual empreendeu em fuga para dentro desta (viela) e depois foi abordada.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do GCM Sérgio (GCM). A ré negou que as drogas fossem dela. Não lembra a quantidade total de drogas, porque foi o encarregado que contou. Tinha duas pessoas próximas da ré, mas estas se evadiram. O fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 14 - 35 papéletes de cocaína, 35 porções de maconha e 67 pedras de "crack") e diversidade (cocaína, maconha e "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, bem como os depoimentos dos guardas civis demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias,

que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciada pelas condutas de adquirir, receber e trazer consigo.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os GCMs se recordarem de todos os detalhes. Porém, foram uníssonos no sentido de que as drogas foram apreendidas em poder da ré.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder da ré (fls. 14 – 35 papérolas de cocaína, 35 porções de maconha e 67 pedras de "crack") demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação da acusada, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 16/19) e laudo definitivo (fls. 71/73).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada à acusada, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 102/103 – proc. 21176-57.2011 – pena a cumprir – execução não iniciada – fls. 104).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 14 – 35 papérolas de cocaína, 35 porções de maconha e 67 pedras de "crack"), já que pequena em Diadema é inferior a 100 porções, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica da acusada. Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

A ré não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primária) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que a condenação anterior também é por tráfico.

Aumento a pena de 1/6, posto que a traficância ocorria nas imediações de instituição hospitalar (Unidade Básica de Saúde do Jardim Inamar), conforme depoimento dos policiais e "croqui" de fls. 78 (a 86 metros da referida unidade de saúde).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art.

33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específica (fls. 102/103 – proc. 21176-57.2011 – execução não iniciada – fls. 117), o que denota personalidade voltada para o crime de tráfico de drogas, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz

natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (presa em 22.11.21, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorrerá em 24.01.25).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA à pena de 7 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que a ré foi presa em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que não há nada que a vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita) e é incabível qualquer benefício, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiária da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 14 e 92 - R\$ 419,50) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 42), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 29 de março de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA